



ANALISTA
SILVIO MACIEL
DIREITO PENAL
AULA 6

ROTEIRO DE AULA

Sumário

Tema: Teoria do Crime- Culpabilidade (elemento do crime)

6- Causas excludentes de culpabilidade (causas dirimentes)

- 6.1 - Anomalia mental (Art. 26, caput do CP) (afasta a imputabilidade)
- 6.2 - Menoridade (Art. 27 do CP e 228 da CF/88) (afasta a imputabilidade)
- 6.3 - Embriaguez involuntária completa (art. 28, §1º do CP e art. 45 da Lei 11.343/06) (afasta a imputabilidade)
- 6.4 - Erro de proibição inevitável (art. 21, segunda parte, do CP) (afasta a potencial consciência da ilicitude)
- 6.5 - Coação moral irresistível (art. 22 do CP)¹ (afasta a exigibilidade de conduta diversa)
- 6.6 - Obediência hierárquica (art. 22 do CP) (afasta a exigibilidade de conduta diversa)

Tema: “ITER CRIMINIS”

- 1.1 “iter criminis”
- 2.1 -Teorias sobre a distinção entre atos preparatórios e executórios
- 3. Tentativa (art. 14, II e parágrafo único, CP)
 - 3.1. Tipicidade Indireta/Mediata
 - 3.2. Punição da Tentativa
 - 3.3. Infrações que NÃO admitem Tentativa:
 - 3.4. Classificação da Tentativa (DOCTRINA)
- 4. Desistência Voluntária e Arrependimento Eficaz (art. 15)

¹ Art. 22 - Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.

(continuação) 6- Causas excludentes de culpabilidade (causas dirimentes)

- Isentam de pena
- Cada causa excludente afasta um dos elementos da culpabilidade e, conseqüentemente, a própria culpabilidade
- O CP adota o sistema vicariante: não permite ao juiz aplicar duas sanções penais cumulativas (pena **OU** medida de segurança)

6.1 - Anomalia mental (Art. 26, caput do CP)² (afasta a imputabilidade)

- Desenvolvimento mental incompleto ou retardado
- Além da anomalia mental são necessários mais dois requisitos:
 - Incapacidade absoluta de entender o que faz
 - Devem estar presentes no momento da conduta
- O art. 26, caput do CP só se aplica se a anomalia estiver presente no momento da conduta, se ocorrer após não haverá a incidência da excludente: será julgado como imputável e condenado (não será isento de pena), havendo mudança apenas no momento de aplicação da pena
- O CP adota o critério biopsicológico
 - Requisito biológico da doença
 - Requisito psicológico da incapacidade mental absoluta
- Ex. infrator tem doença mental, mas compreende tudo o que faz;
 - É imputável
 - Aplicando-se a pena
- Ex. infrator tem doença mental, mas compreende parcialmente o que faz;
 - É semi-imputável
 - Podendo ser aplicada a pena (diminuída de 1/3 a 2/3) ou
 - Aplicar medida de segurança substitutiva dessa pena diminuída
 - A sentença que aplica medida de segurança ao semi-imputável é sentença condenatória (juiz condena, aplica pena diminuída e depois faz a substituição pela medida de segurança – medida substitutiva)

² Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

- Ex. infrator tem doença mental, mas não compreende o que faz;
 - É inimputável
 - É isento de pena
 - Aplica-se medida de segurança
- A sentença que aplica medida de segurança ao **inimputável**, é sentença **absolutória** (sentença de absolvição imprópria)
 - Juiz absolve o inimputável, mas aplica a medida de segurança (“absolvição com aplicação de sanção”)
- Não se prova a inimputabilidade por doença mental sem prova pericial

6.2 - Menoridade (Art. 27 do CP e 228 da CF/88) (afasta a imputabilidade)³

- Adota-se o critério biológico
 - Basta a situação biológica da idade
 - Não importa o critério mental do entendimento
 - Presunção legal absoluta de inimputabilidade
- A inimputabilidade pela idade é verificada no momento da conduta e não no momento do resultado (visto que o tempo do crime é regido pela teoria da ação/atividade)
 - Ex. Menor com 17 anos e 6 meses atira em vítima; mesmo que a vítima faleça apenas depois de 7 meses do tiro disparado pelo menor (já será maior de idade), ele não responderá pelo crime
- Se for crime permanente ou continuado, o STJ e a doutrina aduzem que se o menor fizer 18 anos durante o crime, responderá normalmente (visto que conduta se prolonga até a maioridade)
 - Ex. menor sequestra vítima, sendo essa libertada apenas quando o menor completar 18 anos (ou seja, cessa o crime apenas quando já maior de idade); nesse caso responderá normalmente pelo crime de sequestro
- Se o crime for continuado, responderá apenas pela série de crimes praticada após maioridade
 - Ex. indivíduo cometeu 10 furtos em continuidade delitiva, 5 como menor e 5 como maior de idade; responderá pelos 5 furtos cometidos como maior de idade
- Autonomia da responsabilidade criminal
 - No Código Civil é possível que menor de 18 anos adquira capacidade civil absoluta (ex. emancipação)

³ Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial.

CF/88 - Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.

- O fato de indivíduo adquirir capacidade civil absoluta não interfere em nada na capacidade criminal
- Ex. mesmo que menor de 18 anos adquira a capacidade civil absoluta, ele continuará absolutamente incapaz para o direito penal

Bloco 2

6.3 - Embriaguez involuntária completa (art. 28, §1º do CP e art. 45 da Lei 11.343/06) (afasta a imputabilidade)⁴

- Do ponto de vista fático, a embriaguez pode ser:
 - Voluntária e incompleta
 - Voluntária e completa
 - Involuntária e incompleta
 - Involuntária e completa
- Nos casos de embriaguez voluntária:
 - Não excluem a culpabilidade
 - Seja completa ou incompleta
 - Art. 28, II do CP⁵
- Nos casos de embriaguez involuntária
 - **Se incompleta**, não exclui culpabilidade (atua apenas como **causa de diminuição de pena**, nos termos do art. 28, §2º do CP)
 - **Se completa, exclui a culpabilidade** (art. 28, §1º do CP)

“Art. 28 - § 1º - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)”

⁴ Art. 28, § 1º - É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Lei 11.343/06 - Art. 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

⁵ Art. 28 - Não excluem a imputabilidade penal:

II - a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos

- Teoria da “actio libera in causa”: transfere a análise do dolo e da culpa do momento da conduta para o momento em que o indivíduo ingeriu a substância
- Se o indivíduo está completamente embriagado no momento do crime (de forma voluntária e completa), está agindo sem consciência e sem vontade, portanto sem dolo e sem culpa:
 - Nos casos de embriaguez voluntária completa, a punição se faz com aplicação da teoria da “actio libera in causa” (ação livre na causa)
 - Repito: Essa teoria transfere a análise do dolo e da culpa do momento da conduta para o momento em que o indivíduo se embriagou
 - Pode, inclusive, ser aplicada para crime omissivo: ex. vigia se embriaga, propositalmente, para não impedir um furto que viu acontecendo
 - Se no momento em que o indivíduo se colocou em situação de embriaguez:
 - Ele previu ou quis o resultado (responde por dolo) ou
 - Se previu o resultado, mas achou que não ocorreria (crime culposo por culpa consciente)
 - Se o resultado era previsível (responde por culpa inconsciente);
 - Se o resultado era imprevisível não responde por nada (fato atípico)
- Se a embriaguez for por drogas, aplica-se o art. 45 da Lei 11.343/06, independente do crime (**critério biopsicológico**)
- Se a embriaguez for por álcool ou substância de efeitos análogos, aplica-se o CP
 - Aqui, as Leis também adotam o **critério biopsicológico**
 - Requisito biológico da embriaguez +
 - Requisito psicológico da incapacidade mental de entender
- Embriaguez patológica – anomalia mental, aplicando-se o art. 26, caput do CP
- Embriaguez preordenada: voluntária e com intenção de cometer o crime → agravante de pena (art. 61 do CP)
- Embriaguez e omissão: ex. vigia sabe que haverá furto no seu local de trabalho e se embriaga de forma proposital para não ter que atuar; responde por furto por omissão (tinha dever de evitar o furto e não agiu)

6.4 - Erro de proibição inevitável/invencível (art. 21, segunda parte, do CP) (afasta a potencial consciência da ilicitude)

Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

- Atento que apenas o erro de proibição inevitável exclui culpabilidade
- O erro de proibição evitável diminui a pena de 1/6 a 1/3
- A primeira parte do art. 21 trata do desconhecimento da lei, não tendo ligação com o erro de proibição:
 - No desconhecimento da Lei:
 - O agente sabe que está praticando conduta proibida, só não sabe que existe lei dizendo que a conduta é crime
 - ex. pescador analfabeto pesca escondido durante a piracema; não sabe que existe a Lei de crimes ambientais que prevê como crime a pesca em período defeso; mas sabe que durante a piracema não pode pescar, tanto que está pescando escondido;
 - Atenuante de pena no caso de crimes (art. 65 do CP) ou
 - Pode ensejar perdão judicial no caso de contravenções penais (art. 8º da LCP)
 - No erro de proibição:
 - O agente não sabe que está praticando crime e;
 - Não tem condição de saber (erro de proibição inevitável e que exclui a culpabilidade) ou;
 - Tinha condições de saber;
- Para saber se é erro de proibição evitável ou inevitável, utiliza-se o critério da valoração paralela na esfera do profano:
 - Se através de juízo leigo (conhecimento de mundo) era possível saber que praticava crime, é erro de proibição evitável;
 - Se com base em juízo leigo não era possível saber que a conduta era crime, está-se diante do erro de proibição inevitável
 - Ex. é ponto comum que matar alguém é proibido
 - Ex. holandês fuma maconha no Brasil, não sabe que é proibido (pois na Holanda é permitido)

Desconhecimento da lei	Erro de proibição
O agente desconhece a existência da lei, mas sabe que está praticando uma conduta proibida. Não exclui culpabilidade (não isenta de pena). Pode apenas:	O agente não sabe que a conduta é proibida. Nesse caso: a) se ele não tinha condições de saber que a conduta era proibida – erro de proibição inevitável, que exclui a culpabilidade;
a) ser atenuante de pena nos crimes (art. 65 do CP); b) ensejar o perdão judicial nas contravenções penais (art. 8º da Lei das Contravenções Penais).	b) se ele tinha condições de saber que a conduta era proibida - erro de proibição evitável, que apenas é causa de diminuição de pena. Obs.: para saber se houve ou não o erro de proibição utiliza-se o critério da valoração paralela na esfera do profano. Não há erro de proibição se o agente, fazendo um juízo leigo (profano) da sua conduta, sabe que o que está fazendo é errado. Ele não precisa fazer um juízo técnico-jurídico da sua conduta para saber que ela é errada. Entretanto, levam-se em conta as características particulares do agente (grau de instrução, cultura, local em que vive etc.) e não a figura do homem médio. Assim sendo, um homem culto pode saber que determinada conduta é proibida, enquanto um homem rústico pode desconhecer que essa mesma conduta é proibida. O primeiro não atua em erro de proibição, mas o segundo atua.

obs. Além do erro de proibição direto, visto aqui (o agente não sabe e não tem condições de saber que sua conduta é proibida), existe o já estudado erro de proibição indireto (descriminante putativa por erro de proibição)

obs.2. A doutrina menciona ainda o erro de proibição mandamental, que ocorre nos crimes omissivos impróprios ou impuros. (o agente acha que sua omissão, na situação, é permitida – ex. segurança de boate diz para cliente que ele está sob risco se ficar ali; o cliente diz que vai ficar; horas depois esse cliente é agredido e o segurança acha que não tem que intervir, pois o cliente foi avisado)

6.5 - Coação moral irresistível (art. 22 do CP)⁶ (afasta a exigibilidade de conduta diversa)

- Coação pode ser:
 - Física e irresistível (exclui a conduta)
 - Moral e irresistível (exclui culpabilidade)
 - Física ou moral resistível (atenuante de pena – art. 65, III, c do CP)
- Apenas a coação moral exclui a culpabilidade
 - Visto que a coação física irresistível exclui a conduta e, portanto, o fato típico (não se pratica conduta, diante da ausência de vontade)
- No caso de coação moral irresistível, tem-se a autoria mediata ou indireta
 - O coautor responderá como autor indireto do crime

⁶ Art. 22 - Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.

- Ex. bandido de organização criminosa coage comerciante para falsificar documento público; quem responderá pelo crime de falsificação de documento público é o bandido na condição de autor indireto

6.6 - Obediência hierárquica (art. 22 do CP) (afasta a exigibilidade de conduta diversa)

- Só se aplica nas hierarquias públicas
 - Ex. soldado da polícia militar pode usar como tese de defesa a alegação que agiu em obediência hierárquica ao tenente
 - Ex. segurança do shopping não pode dizer que cumpriu ordens de seu gerente/administrador
- Ordem legal
 - Superior não comete crime
 - Subordinado não comete crime
 - Ambos agiram no estrito cumprimento do dever legal
- Ordem manifestamente ilegal
 - Superior comete crime
 - Subordinado comete crime
- Ordem que não é manifestamente ilegal (é ilegal, mas não está evidente)
 - Superior comete crime (pois sabe que é ilegal)
 - Subordinado é isento de pena
 - Também se trata de autoria mediata ou indireta

Bloco 4

“ITER CRIMINIS”

1.1 “ITER CRIMINIS”

a) Conceito: é o caminho do crime, ou seja, as etapas percorridas pelo criminoso na realização do cometimento do delito. A doutrina, didaticamente, divide em 4 etapas.

b) Etapas:

-cogitação (pensamento) => NUNCA é punida;

-preparação/atos preparatórios (antecede o início da execução) => em regra, NÃO é punida; salvo se, por si só, configurar algum crime. Ex: aluguel de carro para praticar racha a noite (alugar carro não é crime); comprar uma arma com numeração raspada (por si só configura crime □ crime obstáculo).

-execução/atos executórios (início do crime) => PUNIDA, pois já existe início de crime. É relevante diferenciar ato preparatório (não punível) de ato executório (punível)

- Consumação: fase em que ocorre o resultado pretendido ou o resultado culposos.

obs. O exaurimento é etapa do crime?

NÃO, porque são acontecimentos posteriores à execução do crime, e que agravam as consequências do crime, ou seja, tornam a conduta mais grave.

Ex: a concussão se consuma com a exigência da vantagem indevida, logo, se o funcionário público receber a vantagem, será mero exaurimento do crime já consumado.

obs. O exaurimento tem consequência jurídica?

SIM, porque o exaurimento se trata de um acontecimento que torna a conduta mais grave, e, por isso, é circunstância judicial a ser considerada pelo juiz na fixação da pena-base.

Observe 2 exemplos e compreenda, com as teorias apresentadas, a distinção entre atos preparatórios e executórios:

Ex 1: agente pulou o muro de uma casa e andando pelo quintal procura objetos, oportunidade que a polícia chega no local. Ato executório ou preparatório de furto?

Ex 2: homicida, atrás da árvore, aguarda a vítima para matá-la, entretanto é avistado pela polícia que passava no local. Ato executório ou preparatório de homicídio?

2.1 -TEORIAS SOBRE A DISTINÇÃO ENTRE ATOS PREPARATÓRIOS E EXECUTÓRIOS

a) Teoria da Hostilidade ao Bem Jurídico (Critério Material): para essa primeira teoria, existe ato executório, desde o momento que o bem jurídico sofre situação de perigo concreto; (nos exemplos acima, há tentativa em ambos)

b) Teoria Objetivo-Individual: já nessa teoria, existe ato executório quando pelo [plano do autor] é possível identificar que o crime começou. (nos exemplos acima: há início de execução em ambos)

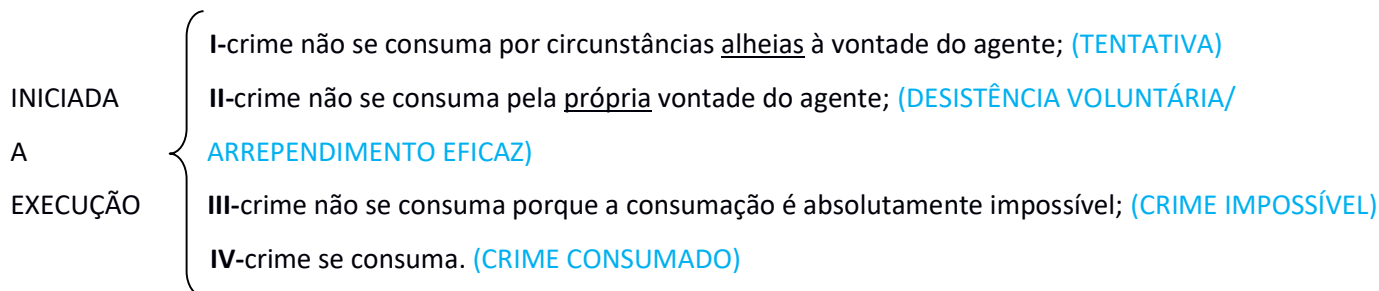
c) Teoria Objetivo-Formal (Critério Objetivo-Formal): de outro modo, para essa teoria, só existe ato executório quando o agente começa a praticar o verbo do tipo penal, ou seja, inicia a prática da conduta nuclear prevista no verbo do tipo penal. (nos exemplos acima, não há início de ato executório de furto ou de homicídio)

É certo que, no Brasil, por uma questão de segurança jurídica, aplica-se a Teoria Objetivo-Formal, sendo assim, no ex. 1 o agente responde por violação de domicílio, e no ex. 2 responde por porte ilegal de arma.

obs. O criminoso precisa necessariamente percorrer as 4 etapas?

NÃO, como por exemplo, nos crimes tentados, nos quais o agente não percorre as 4 etapas.

Observe que após o início da execução poderá ocorrer as seguintes hipóteses:



3. Tentativa (art. 14, II e parágrafo único, CP) (“CONATUS”/CRIME IMPERFEITO/CRIME INCOMPLETO)

- Há tentativa quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente (art. 14, II do CP)

-O dolo da tentativa é o mesmo dolo do crime consumado.

3.1. Tipicidade Indireta/Mediata

Na tentativa ocorre uma Tipicidade Indireta/Mediata, porque a conduta do agente não se enquadra diretamente no tipo penal incriminador, sendo necessária a NORMA DE EXTENSÃO TEMPORAL do art. 14, II

Ex: [A] tenta matar [B] = art. 121 + art. 14 -> significa dizer que, como o art. 121 pune a conduta de matar, e o agente tentou, MAS não matou a vítima: é necessário a NORMA DE EXTENSÃO TEMPORAL do art. 14, II, que pune a tentativa.

Lembre-se que NORMA DE EXTENSÃO TEMPORAL é aquela que permite antecipar a punição para momento anterior à ocorrência do resultado.

3.2. Punição da Tentativa (art. 14, parágrafo único)

Na punição da tentativa existem 2 teorias:

a) TEORIA SUBJETIVA/VOLUNTARÍSTICA/MONISTA => leva em conta a intenção do agente, ou seja, a punição da tentativa é a punição da consumação.

-> CP adota como **exceção**: por exemplo, art. 352.

-> crimes de atentado ou empreendimento: tentativa punida com a mesma pena do crime consumado, sem qualquer redução

b) TEORIA OBJETIVA/REALÍSTICA/DUALISTA => leva em conta o grau de ofensa ao bem jurídico, ou seja, a punição da tentativa é MENOR que a punição da consumação.

- > CP adota como **regra**: punição da tentativa = pena cominada para o crime consumado diminuída de 1/3 a 2/3
- > redutor da tentativa é direito **subjetivo do réu**; juiz é obrigado a aplicar
- > a discricionariedade do juiz está no quantum redutor
- > para dosar a diminuição o juiz utiliza o CRITÉRIO DA PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO (quanto mais próximo o agente chegou da consumação menor a diminuição).

Bloco 5

3.3. Infrações que NÃO admitem Tentativa:

a) Crime Culposo (crime que o agente não quer o resultado)

Atenção: a **culpa imprópria** (também chamada de culpa por equiparação/assimilação/extensão) **ADMITE** a tentativa porque, na verdade, é uma ação dolosa punida como crime culposo em razão do erro do agente, que responde por tentativa de crime culposo.

Lembre-se que a culpa imprópria ocorre quando o agente, por erro evitável, supõe, equivocadamente, que está em uma situação de excludente de ilicitude, que na verdade não existe (culpa imprópria = ação dolosa, punida pelo legislador como crime culposo, por conta do erro do agente). Ex: morador da casa atira dolosamente no vizinho pensando ser um assaltante.

b) Crime Preterdoloso/Preterintencional (crime com dolo na conduta e culpa no resultado).

- resultado culposo

c) Crime Omissivo Puro/Próprio (aquele que a conduta descrita no tipo penal é uma omissão).

Atenção: **crime omissivo impuro/impróprio** (aquele em que o tipo penal incriminador descreve uma ação, mas o resultado é alcançado por uma omissão) **ADMITE** tentativa. Ex: salva-vidas, por ser inimigo da vítima, a deixa afogar, vindo a ser salva por outro banhista que estava no local.

d) Crime Unissubsistente (crime que a conduta é composta por um único ato, logo, não pode ser fracionada em atos).

- ex. injúria verbal

e) Crime de Atentado/Empreendimento (aquele crime que a tentativa já é punida como crime consumado).

- ex. art. 352

f) crimes que só são punidos se ocorrer o resultado (crimes condicionados)

g) Crime Habitual (crime que somente se configura se houver uma reiteração de atos).

h) contravenção penal

A contravenção penal admite a tentativa?

SIM, porém **não é punida** por opção do legislador.

Os crimes de ímpeto admitem tentativa? (o que não foi premeditado)

SIM

Os crimes formais e de mera conduta admitem a tentativa?

SIM, desde que sejam plurissubsistentes.

Os crimes cometidos com dolo eventual admitem a tentativa?

SIM, conforme doutrina e jurisprudência.

3.4. Classificação da Tentativa (DOCTRINA)

-Tentativa Branca/Incruenta = vítima NÃO é atingida;

-Tentativa Vermelha/Cruenta = vítima é atingida;

-Tentativa Idônea = resultado era POSSÍVEL de ocorrer;

-Tentativa Inidônea/Inadequada = resultado era ABSOLUTAMENTE impossível de acontecer (apelido doutrinário do crime impossível);

-Tentativa Perfeita (crime falho) = agente ESGOTA todos os meios (o resultado não ocorre por razões contrárias à sua vontade);

-Tentativa Imperfeita = agente NÃO ESGOTA todos os meios de execução (não atinge o resultado);

-Tentativa Abandonada ou Qualificada = apelido doutrinário da Desistência Voluntária e do Arrependimento Eficaz (serão abordados na aula seguinte)